

1500434-63.2022.8.26.0544
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Renata Marques de Jesus
Comarca: Francisco Morato
Foro: Foro de Francisco Morato
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 25/07/2022
... o C. Superior Tribunal de Justiça:

"DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. O § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Francisco Morato
Foro de Francisco Morato
1ª Vara
Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato - SP - cep 07910-220
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500434-63.2022.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500434-63.2022.8.26.0544
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MARLON APARECIDO DORNELAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Marques de Jesus

Vistos.

MARLON APARECIDO DORNELAS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e artigo 180, "caput", do Código Penal, ambos c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 18 horas, na Rua do Engenho, altura do nº 213, Jardim Casa Grande, nesta cidade e Comarca de Francisco Morato, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 04 (quatro) porções de "maconha" (cannabis Sativa L.), com peso líquido aproximado de 294,25g (duzentos e noventa e quatro gramas e vinte e cinco centigramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, ainda, que em data, horário e local incertos, adquiriu e ocultou, em proveito próprio, uma motocicleta da marca Honda, modelo CG, de cor verde, com placa falsa HBF1B20 e o número do chassi suprimido, que sabia ser produto de crime (fls. 1/4).

Preso em flagrante delito (fls. 5), a prisão foi convertida em preventiva (fls. 62/64).

Notificado (fls. 115/116), o réu apresentou defesa prévia (fls. 119/120) e a denúncia foi recebida (fls. 133/135). Citação às fls. 160.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e o réu interrogado (fls. 164/166). Mídias arquivadas.

Em debates o Ministério Público pugnou pela procedência nos termos da denúncia, com imposição de regime inicial fechado (fls. 161/163). A Defesa, por sua vez, requereu em alegações finais escritas a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, do SISNAD, e, em caso de condenação, a fixação de pena privativa de liberdade mínima e conversão desta em restritiva de direitos, bem como o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal (fls. 170/174).

É o relatório.
Fundamento e decido.

À luz das provas carreadas aos autos, a pretensão inicial merece prosperar.

A materialidade restou comprovada ante o auto de prisão em flagrante (fls. 5/11), boletim de ocorrência (fls. 13/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), laudo de constatação provisória (fls. 19/26), além do exame químico-toxicológico de fls. 156/158, que constatou a presença de tetrahydrocannabinol (THC) nas amostras analisadas.

Igualmente demonstrada a materialidade do crime de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) do veículo apreendido (fls. 17/18), especialmente pelas fotografias de fls. 27/28 e pelo laudo de fls. 153/155, que constatou a falsidade da placa de identificação veicular.

A autoria também é certa, corroborada pela própria confissão extrajudicial (fls. 11), reconhecendo ter em depósito o entorpecente apreendido, alegando ser para uso próprio, e, também, que comprou o veículo.

Em juízo o réu declarou ter 29 anos de idade, ter dois filhos menores de idade, trabalhava como motoboy, com renda de R\$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), morar em casa alugada, não conhecer as testemunhas arroladas e já ter sido processado por furto e "se arrependeu". Sobre os fatos disse que a moto era sua e já a tinha um tempo. Tinha "nota fiscal de leilão", mas acabou perdendo. Estava dentro de sua casa e os policiais bateram na sua porta. Mora com sua esposa e filho, que tinham saído no dia. Seu cunhado estava dormindo. Tinha droga dentro da geladeira. Não soube dizer quanto, mas gasta cerca de R\$ 300,00 (trezentos reais) em maconha para seu consumo, evitando ter que "ir sempre comprar". Consome cerca de 20 a 30g por dia. Não foi abordado fora de casa. Esclareceu que sua esposa também fuma maconha (fls. 166).

Diogo da Silva Oliveira, policial militar que participou da ocorrência, afirmou, no mesmo sentido de seu depoimento extrajudicial às fls. 6, que estava patrulhando na via citada na denúncia e avistaram o acusado ao longo da via. Ao avistar a equipe ele correu para dentro de um quintal. Desembarcaram da viatura e o alcançaram. Em revista pessoal ele tinha uma porção de maconha no bolso da frente, além de R\$ 120,00. Indagado, ele relatou à equipe que estava na venda da droga e que dentro da residência tinha mais. Ele abriu a porta e apontou onde estavam as demais quantidades de entorpecente, que estavam na geladeira. A moto estava no quintal e ele disse que era de sua propriedade. O acusado não apresentou nota ou qualquer outro documento. Em revista veicular verificaram numeração suprimida do chassi e a

placa tinha indícios de falsificação, sem o QR Code. O local era conhecido como ponto de venda de droga. Só tinha maconha e estava embalada em sacos separados. Não se lembrou da quantidade exata da droga. Na residência tinha mais um indivíduo no quarto, dormindo, que foi conduzido para a delegacia. Não acompanhou o depoimento dessa pessoa, de prenome Luiz. Esclareceu que ao ser indagado sobre os fatos o réu estava fora da residência e só verificaram a presença do outro rapaz após o acusado abrir a casa. Tinham pessoas passando pela rua no momento (fls. 164).

Na mesma esteira o depoimento extrajudicial do também policial militar Diogo Levy Ferreira (fls. 7) que, em juízo, manteve sua versão e contou que em patrulhamento de rotina na via citada o indivíduo se evadiu e entrou em um quintal. Abordado, com ele havia droga no bolso da bermuda e disse estar na venda de droga no local. Avisou que dentro da residência tinha mais droga e, apontando o local, localizaram mais maconha. A moto estava no quintal e o réu alegou ser dele. Comprou de um amigo, que disse ser de leilão. Não conhecia o acusado antes dos fatos. Não se recordou da quantidade de droga encontrada. Na residência tinha um rapaz dormindo, que seria amigo e vizinho (fls. 165).

É importante salientar que a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos. Há de se levar em conta que o acusado e os policiais militares não se conheciam até então, de forma que estes não tinham motivos para acusá-lo leviana e gratuitamente.

Ademais, a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho caso venham a sonegar ou adulterar os fatos. Aliás, nem teria sentido conferir-lhes a lei determinada tarefa para depois, quando viessem prestar contas de sua atuação, negar-lhes valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não dizem a verdade:

“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte” (STJ, Sexta Turma, AgRg no Ag 1158921/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julg. 17/05/2011, DJe 01/06/2011);

“O depoimento de policial obedece os mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional” (TJSP, RT 752/586);

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC nº 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18/02/97, DOU de 11/04/97, p. 189);

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário é de idoneidade destas testemunhas, ainda mais quando os seus depoimentos são seguros precisos e uniformes desde a sede inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (TJSP, RT 614/275);

“Os policiais não são proibidos de prestar depoimento nos processos de cuja fase policial tenham participado, seja efetuando a prisão do agente, seja apreendendo o objeto do crime. De outro lado, a declaração de inidoneidade é específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, devendo ser alegada e demonstrada em cada caso” (TJMG, RT 604/407).

A partir do contexto probatório extrai-se que as testemunhas prestaram depoimentos coesos e convergentes, reafirmando as declarações prestadas na fase policial, tornando seguro um decreto condenatório.

E, não demonstrou a Defesa eventual motivo que os policiais militares teriam para mentir em juízo deixando, assim de se desincumbir de seu ônus (artigo 156, do Código de Processo Penal), destacando que eventuais e pequenas contradições entre os depoimentos, sequer existentes na hipótese, não são capazes de infirmar a lisura do trabalho policial. Nesse sentido:

“PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato” (TACrimSP - Ap. nº 583.153/2 - 7ª Câmara - Rel. José Habice - J. 05.04.90 - RJDTACRIM 6/78).

A Defesa tenta, em vão, diminuir o valor dos depoimentos dos policiais (fls. 171/172), o que não se sustenta diante do quadro probatório existente e dos elementos de convicção formados.

Nesse ponto, é preciso ficar claro que a inexistência de testemunhas civis e 'eventuais compradores' no ato da prisão em flagrante não o invalida, cumprindo ressaltar que em delitos da espécie, como cediço, ainda que populares presenciem a atividade criminosa, estes não querem se identificar com medo de represálias por parte dos criminosos.

Dentro desse quadro, os depoimentos das testemunhas comuns ouvidas sob o crivo do contraditório, repita-se, foram harmônicos e convergentes, levando à certeza da autoria.

Sendo assim, pela quantidade da droga apreendida e as circunstâncias da prisão do réu, destacando-se ter sido efetuada nas proximidades de ponto de venda de entorpecentes, bem como o depoimento seguro prestado pelas testemunhas, levam à certeza de que o réu traficava drogas na ocasião.

Destaca-se que o crime de tráfico de entorpecente é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário, pelo que as simples condutas do réu, consistentes em “trazer consigo” e “ter em depósito” as substâncias entorpecentes, já são suficientes para caracterização do delito:

“Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para esta destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado” (TJSP - Apel. Crim. nº 990.09.088010-4 - 5ª Câmara Criminal - Campinas - v.u. - j. 03.09.09 - Rel. Des. Pinheiro Franco).

No mesmo sentido:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663);

"Não é indispensável à prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (RT 729/542);

"Cabe ressaltar que para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da prisão para evidenciar tal atividade ilícita". (TJ/SP - Apel. Crim. nº 990. 09.235417-5 - 14ª Câmara Criminal - v.u. - j. 11.03.10 - Rel. Des. Fernando Torres Garcia).

Ressalta-se que a considerável quantidade do entorpecente, além da forma como se deu sua apreensão demonstram a traficância e não autorizam a classificação da conduta como simples consumo pessoal (artigo 28, da Lei nº 11.343/06):

"DESCCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE USO - Inadmissibilidade - Quantidade e diversidade de entorpecentes - Conjunto probatório suficiente para ensejar o decreto condenatório - Inexistência de prova segura que autorizasse decretar nova definição jurídica da conduta." (TJSP, 16ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 990.08.080898-2, Des. Rel. Leonel Costa, j. 28/04/09).

E o fato de o acusado afirmar que é usuário de droga e que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao consumo próprio não é suficiente para a desclassificação do delito de tráfico, sendo, repita-se à exaustão, a condenação de rigor. Vale destacar, ainda, que a condição de usuário não é incompatível com a de traficante:

"(...) a mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra." (TJSP, AC nº 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP RJTJSP 101/498);

"Importante consignar que o fato de o acusado ter declarado que era usuário de drogas não afasta sua condição de traficante, uma vez que os usuários, frequentemente, também passam a comercializar entorpecentes, justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento, acrescentando-se, por oportuno, que uma conduta não exclui a outra" (TJSP; 9ª Câmara Criminal, Ap. n.º 0001866-59.2015.8.26.0635, Rel. Sérgio Coelho, j. em 31.03.2016);

"Nenhuma incompatibilidade existe entre o tráfico de entorpecente e o vício. Ao contrário. Em regra, vivem associados" (RT 411/104).

Cabe observar, nesse passo, que a apreensão de não desprezível quantidade de substância entorpecente em poder do agente, além da circunstância de estar separada em unidades diferentes ou dividida em porções, conduz à segura conclusão de que se destina ao comércio ilícito, e não ao uso próprio.

No que tange ao também imputado delito de receptação do veículo motocicleta Honda CG 125, placa HBF1B20, igualmente comprovada a autoria e materialidade. Observa-se

que o denunciado adquiriu e recebeu coisa que, pela condição de quem oferecia, devia ter presumido ser obtida por meio criminoso, destacando-se a falsificação grosseira da placa, que não consta QRCode, item de identificação obrigatório das placas Mercosul agora padronizadas. O acusado aduziu em juízo ter comprado a motocicleta de um amigo, sem informação do nome deste ou do valor da aquisição, revelando negociação de forma extremamente informal e em contradição ao interrogatório extrajudicial, onde disse que "comprei de um rapaz que desconheço, que me disse que era de leilão" (fls. 11), sendo evidente que não adotou comportamento esperado pelo homem médio de regular cautela e prudência em vendas de veículos.

Destaco, ademais, que em momento algum exigiu documento do suposto "vendedor" documento do veículo e do mencionado "leilão", não tendo, igualmente, buscado o registro junto ao órgão competente e transferência para seu nome, situações que tornam cristalina a ciência criminosa e procedência ilícita do bem.

Patente sua ciência, a fim de caracterizar o delito de receptação, em razão das circunstâncias. Vale lembrar que o fato de ter sido surpreendido na posse da coisa com origem ilícita inverte o ônus da prova, dele não se desincumbindo o réu, que não exibiu qualquer documento que comprovasse a aquisição lícita.

"A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração" (TACRIM - SP - AC - Rel. Juiz Nogueira Filho - JUTACRIM 96/240).

"Deveras, no caso de receptação dolosa, a presença do elemento subjetivo ciência da origem ilícita do bem pode derivar 'de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi' do agente, porquanto 'não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva' (TACRIM-SP, RJDTACrim 35/286, rel. José Habice. Na mesma linha, TACRIM-SP RJTACrim 30/63, rel. Barbosa de Almeida, apud Alberto Silva Franco e outros, Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, Parte Especial, 7ª edição, pág. 2.960).

!Vale dizer, admite-se que o conhecimento, por parte do agente, da procedência espúria do bem venha a ser demonstrado por indícios (cfr. Jurisprudência mencionada por JULIO FABRINI MIRABETE, Código Penal Interpretado, Atlas, 5ª edição, págs. 1670/1671)." (TJSP, 2ª Câmara Criminal, Apelação nº 0003160-39.2010.8.26.0210, Des. Laerte Marrone, julgado em 23/02/2015).

"É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em se cuidando do crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato" (TJSP, AP nº 0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, julgado em 10/11/2011).

"Nos crimes de receptação, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí por que a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente" (TACRIM-SP - AC - Rel. Renato Mascarenhas - JUTACRIM 83/242).

Como se vê, a prova existente permite a convicção de que o réu tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem que recebera, em proveito próprio, sendo de rigor a procedência da pretensão punitiva estatal.

E impossível a absolvição, tampouco a desclassificação para delito culposos. 0

conhecimento da origem espúria do bem pelo receptador, óbvio dizer, não admite prova direta, dada a impossibilidade de penetração e exame na mente do agente.

Entretanto, são perfeitamente admitidos meios indiretos de comprovação de que a ilicitude não lhe era estranha, sobretudo em vista dos indícios ou circunstâncias exteriores, por vezes bastante eloquentes. Assim não fosse, o êxito da persecução dependeria, exclusivamente, da confissão. O adquirente que recebe bem espúrio não dispõe de explicações para a posse da coisa ou, se dispõe, são informes vagos ou dissociados da realidade; ademais, sem pretender esgotar o tema, a aquisição ilícita não raro se dá conforme trâmites informais que evidenciam a própria ilegalidade. Nesse sentido também a Jurisprudência:

“Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do *modus operandi* do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva” (RJDTACRIM 35/285-6).

O dolo na hipótese, pois, extrai-se das circunstâncias de fato que cercaram a aquisição da coisa produto de ilícito anterior.

Destarte, comprovadas a autoria e a materialidade, inexistindo causa de exclusão da ilicitude, a ação penal é procedente, amoldando-se as condutas praticadas pelo réu ao artigo 33, caput, do SISNAD e artigo 180, caput, do Código Penal, como se demonstrou.

Passo a dosar a pena:

a) Em relação ao delito de tráfico de drogas - Sopesados os elementos norteadores do art. 59, do Código Penal e em observância ao disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal, perfazendo 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de de 500 (quinhentos) dias-multa.

Prosseguindo, nos termos do artigo 68, do Código Penal, verifico a ausência de qualquer circunstância atenuante que possa ser aplicada no caso concreto.

Ainda nesta fase, deve ser reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, alínea “j”, do Código Penal, na medida em que o crime foi cometido durante o período da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), quando já estava decretado o estado de calamidade pública, com recomendação do isolamento social e outras medidas públicas (Decreto Estadual nº 64.879/20 e Decreto Legislativo nº 6/2020), o que reduz a vigilância.

A prática de crime em cenário no qual toda a população passa por privações e incertezas e em meio a diversas recomendações de recolhimento domiciliar e restrição de atividades de toda ordem é ainda mais reprovável e merece resposta penal diferenciada. A situação atualmente vivida é excepcional e, sem dúvida, do conhecimento de todos, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. APELO MINISTERIAL. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "J", DO CÓDIGO PENAL, E DE AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO, COM READEQUAÇÃO DAS PENAS. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal, valoradas como negativas as circunstâncias relacionadas à natureza da droga (cocaína, acondicionada na forma de tijolos) e do seu transporte entre cidades. Na segunda etapa, pedido ministerial acolhido, para reconhecimento da agravante da prática de crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, "j", do CP). Prática do crime durante a pandemia de COVID-19. Lei não

prevê nenhuma condicionante finalística ou modal para que a agravante incida. Mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, as penas ainda foram reduzidas em 1/10, dada a preponderância da atenuante (art. 67, CP). A quantidade dos entorpecentes apreendidos (quase dois quilogramas de cocaína) e seu alto valor no comércio clandestino de entorpecentes demonstram envolvimento do apelado em atividades criminosas, impedindo, portanto, a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o qual fica afastado. Penas redimensionadas para 5 anos e 3 meses de reclusão e 524 dias-multa. REGIME PRISIONAL. Imposição do regime inicial fechado, ante a pena concretizada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, parágrafo 3º, do Código Penal), a par da gravidade concreta do delito praticado. BENEFÍCIOS LEGAIS. Incabível a concessão de sursis ou de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a quantidade de pena concretizada, Recurso ministerial provido para, afastado o privilégio e reconhecida a agravante do art. 61, II, "j", do CP, redimensionar as penas do apelado, bem como fixar-lhe o regime inicial fechado." (TJSP; Apelação Criminal 1522780-54.2020.8.26.0228; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2021; Data de Registro: 28/04/2021) - grifos nossos.

Prosseguindo, ainda na fase intermediária, verifico que o réu é reincidente (fls. 38/43), na forma do artigo 61, inciso I e artigo 63, ambos do Código Penal, devendo a pena ser acrescida em 1/6 (um sexto), passando a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase não é o caso de incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ou seja, do reconhecimento do crime de "tráfico privilegiado", pois se trata de uma benesse que deve ser aplicada em casos pontuais em que há pequeno potencial de lesividade ao bem jurídico tutelado, o que, obviamente, não é o caso do réu.

O referido § 4º prevê que o benefício será aplicado ao agente que, além de ser primário e portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Restou demonstrado que o réu é reincidente e trazia consigo elevada quantidade de entorpecente a indicar envolvimento no comércio de drogas, ou seja, a não ocasionalidade da conduta. Quadro, pois, a desnudar que se trata de pessoa dedicada às atividades criminosas.

É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça que a dedicação à atividade criminosa é óbice à aplicação da causa de redução de pena, independentemente do grau de comprometimento do agente com o crime, ou da complexidade da estrutura da organização criminosa (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1.357.182/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013).

Enfim, havendo indícios do envolvimento do acusado com a criminalidade, descabido o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, valendo trazer à colação, como já se decidiu, que a conduta social do réu, a quantidade e a natureza do entorpecente, além das circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa (RHC nº 116.926/DF, rel. Min. Luiz Fux, j. em 20.8.2013; HC nº 116.541/ES, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6.6.2013; HC nº 98.366/MG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.2.2010).

Nesse sentido o C. Superior Tribunal de Justiça:

"DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. O § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de

tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. No caso em análise, com base na grande quantidade de drogas apreendidas, as instâncias ordinárias concluíram que o paciente dedica-se à atividade criminosa. 3. "Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa" (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 21/08/2018). 4. Embora a quantidade de entorpecentes apreendidos já tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria penal, para exasperar a pena-base, nada impede que tal circunstância seja novamente considerada na terceira etapa, para aferir a traficância habitual e, conseqüentemente, obstar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006." (AgRg no HC 499936 Rel. Min. Jorge Mussi julg. 25/06/2019 publ. 01/07/2019)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE AUMENTO DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. AGENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HISTÓRICO CRIMINAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APLICAÇÃO DA NORMATIVIDADE REGENTE. QUANTUM DE PENA A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...) VI - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na grande quantidade e na natureza da droga apreendida, ou seja, "670 g de maconha". Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional" (Quinta Turma, AgRg no HC 548913/MS. Relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo. Julgado em 10/03/2020. DJe 18/03/2020)

A pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, torna-se definitiva, tendo em vista a inexistência de outras causas de aumento e de diminuição.

O valor do dia-multa deve ser calculado nos termos do artigo 43, da Lei nº 11.343/06, sendo fixado em um trinta avos do salário mínimo vigente à época do pagamento, tendo em vista a situação econômica do acusado.

Além disso, não se pode olvidar a natureza da infração e os males que ela provoca no seio social, devendo o infrator experimentar repercussões objetivas acerca da censurabilidade de sua conduta, razão pela qual o réu deverá cumprir sua pena em regime inicialmente fechado:

"TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. Ressalto que há determinação expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP; 6ª Câmara de Direito Criminal; AP 0057527-71.2011.8.26.0050; Relator Marco Antonio Marques da Silva, data do julgamento: 27/06/2013).

Vale lembrar que embora o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90 (HC 111.840/ES), a r. decisão não foi unânime e foi feita de forma incidental, não possuindo eficácia erga omnes e nem efeito vinculante.

E, não sendo o caso de reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, do

art. 33, da Lei nº 11.343/06, conforme justificado, não há que se falar em aplicação da determinação proferida no Habeas Corpus Coletivo nº 596.603/SP, do C. Superior Tribunal de Justiça (Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz), que determinou a fixação do regime aberto em relação aos presos que “se encontrem na mesma situação (condenados, por delito de tráfico privilegiado, a 1 ano e 8 meses, em regime fechado)”, estabelecendo, dentre outras determinações, que “aos condenados que atualmente cumprem pena por crime de tráfico privilegiado, em que se reconhecem todas as circunstâncias como favoráveis, e aos que vierem a ser sancionados por tal ilicitude (mesmas circunstâncias fáticas), determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena” (grifo nosso).

In casu, impossível a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, diante do montante da pena, da reincidência e também da gravidade concreta do delito, tendo em vista a quantidade das drogas apreendidas, somando um total líquido aproximado de 300g, o que justifica a não substituição da reprimenda (STJ, Quinta Turma, HC 24914/SP, Rel. Min. Marilza Maynard, j. 14/04/2013):

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - 11,2G DE COCAÍNA, 179,1G DE MACONHA E 554ML DE LANÇA-PERFUME - PENAS - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "j" - IMPOSSIBILIDADE - O NECESSÁRIO ISOLAMENTO SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS GARANTIU, POR INFELIZ VIA TRANSVERSA, O ANONIMATO E A IMPUNIDADE DE USUÁRIOS E TRAFICANTES - AGRAVANTE MANTIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA A INDICAR QUE O ACUSADO, CONQUANTO PRIMÁRIO, FAZ DO TRÁFICO SEU MEIO DE VIDA - REGIME FECHADO ADEQUADO - EVENTUAL ABRANDAMENTO NÃO SERIA SUFICIENTE PARA ATENDER AO ASPECTO QUALITATIVO DA PENA - IMPROVIMENTO DO RECURSO" (TJSP; Apelação Criminal 1514354-53.2020.8.26.0228; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 19/10/2020) - grifos nossos

Ademais, tais benefícios são incompatíveis com a finalidade da Lei nº 8.072/90, que dá tratamento mais rigoroso aos chamados crimes hediondos e assemelhados e que prevê, dentre outras hipóteses, a fixação de regime inicial fechado para cumprimento da sanção imposta ao protagonista de delitos deste jaez.

b) Em relação ao delito de receptação - Sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, nesta primeira fase de aplicação de pena, mantenho as penas bases no patamar mínimo legal, fixando-a, portanto, em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Prosseguindo, verifico que o réu é reincidente (fls. 38/43), devendo a pena ser acrescida em 1/6 (um sexto), passando a 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Ainda nesta fase deve ser reconhecida a agravante genérica prevista no artigo 61, II, "j" do Código Penal, na medida em que o crime foi cometido durante o período da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), quando já estava decretada calamidade pública, com recomendação do isolamento social e outras medidas públicas (Decreto Estadual nº 64.879/20 e Decreto Legislativo nº 6/2020), o que reduz a vigilância, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em 01 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Ausentes outras agravantes e/ou atenuantes, bem como causas de aumento e/ou diminuição, torno a reprimenda definitiva.

Sem parâmetros para elidir a presunção de hipossuficiência econômica do réu, fixo o

valor de cada dia-multa em seu mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento deverá ser o semiaberto, tendo em vista ser o réu ser reincidente em crime doloso.

O acusado é reincidente, lembrando que a generalidade do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal, não basta para a aplicação do regime aberto a todos os condenados a pena de prisão inferior a quatro anos.

Para garantir-se o princípio constitucional da individualização devem ser observadas sempre as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, que são desfavoráveis à ré. Aliás, é isso que dispõe o § 3º, do mencionado artigo 33.

Frente ao imperativo de se examinar particularmente cada caso para se fazer um juízo claro de necessidade e suficiência da reprimenda, não apenas com relação à quantidade dela, mas também quanto ao regime, dentre os previstos em lei, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade sob regime semiaberto.

Ausentes os requisitos legais, notadamente porque as infrações pelas quais condenado foram em concurso material, na forma do artigo 69, do Código Penal, tendo sido, inclusive, condenado a cumprir pena privativa de liberdade pelo tráfico de drogas, vedada a substituição da pena privativa de liberdade ora aplicada em relação ao crime de receptação, conforme dispõe o artigo 69, §1º, do Código Penal: " § 1º - Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste Código."

Diante da persistência dos requisitos que mantiveram a prisão cautelar durante o curso do processo, o acusado não poderá recorrer em liberdade. Assim, deverá manter-se recolhido para poder recorrer, até porque seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou:

"(...)6. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a perseguição criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (...)"(STJ, HC 449692/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado 23-08-2018).

Expeça-se mandado de prisão, recomendando-se na prisão em que se encontra, bem como guia de recolhimento provisória, encaminhando-a, com as peças obrigatórias, ao Juízo da Execução competente.

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido para:

A) condenar MARLON APARECIDO DORNELAS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 180, caput, c/c artigo 61, II, "j", do Código Penal a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, estes no valor mínimo legal; e em concurso material, na forma do artigo 69, do Código Penal, também

B) condenar MARLON APARECIDO DORNELAS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 61, II, "j", do Código Penal, a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa estes no valor mínimo legal.

Em observância ao disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, verifico que o réu encontra-se preso preventivamente a pouco mais de cinco meses,

contudo, não há elementos nos autos - principalmente os subjetivos - para eventual colocação em regime mais benéfico, que fica condicionada à demonstração de que ostenta bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional, bem como à verificação de que não se encontra preso/a, provisória ou definitivamente em razão de outro processo.

Eventual progressão, portanto, quando cabível, deverá ser verificada em sede do Juízo das Execuções Criminais, a ele competindo proceder às adequações necessárias em caso de existência de outras condenações penais, nos termos dos artigos 66, III, "a" e 111, ambos da Lei nº 7.210/84:

"Finalmente, é inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria." (TJSP - 5ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 - Rel. Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.).

Autorizo a incineração das drogas, nos termos dos artigos 50, §§ 3º e 4º e 72, ambos da Lei de Tráfico, destruindo-se amostras guardadas para contraprova. Comunique-se nos termos dos art. 524-A, § 2º, e 525, das NSCGJ, caso tal providência ainda não tenha sido adotada.

Nos termos dos artigos 63, I e § 1º, e 64, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento da quantia apreendida, pois decorrente da prática do crime em questão. Oficie-se, após comprovação pela autoridade policial do depósito do referido valor nos autos, caso tal providência ainda não tenha sido adotada.

Em relação ao veículo apreendido (fls. 17/18), com chassi suprimido e emplacamento falso, nos termos do artigo 123 do Código de Processo Penal, determino avaliação e, caso possua valor econômico, que seja vendido em leilão público, senão, destruído. Oficie-se ao diretor da Ciretran local para as providências cabíveis, devendo comunicar este Juízo das medidas adotadas.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03, condenado, o réu arcará com as custas processuais:

"o réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei 1.060/50. Precedentes. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase da execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação" (REsp. 400.682, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 17/11/ 2003,). No mesmo sentido: REsp. 262.961, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 17.06/2002; REsp. 263.021, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 18.03/2002 e REsp. 81.304, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 14/09/98. Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso." - grifos nossos (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0008903-30.2009.8.26.0189, Relator Des. Euvaldo Chaib)

Expeça-se certidão de ao advogado nomeado nos autos (fls. 117) nos termos da tabela DPE/OAB vigente.

Após o trânsito em julgado oficie-se ao TRE, para fins do disposto no artigo 15,

III da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva e arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.

P.I.C.

Francisco Morato, 22 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA